

1517384-28.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517384-28.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517384-28.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE, registrado civilmente como FELLIPE CORDEIRO MORATO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

FELIPPE CORDEIRO MORATO foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, na data de 03 de agosto de 2022, por volta das 13h30min, na Alves Porto, nº 68, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 tijolo, contendo 238g (duzentos e trinta e oito gramas), de substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha" e diversas porções, contendo 7,7g (sete gramas e sete decigramas), de substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como "skunk", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudo de constatação provisória de fls. 08/11). Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora. Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado. Ponderações finais das partes em debates. Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 12. Laudo de Constatação, a fls. 08/11. Laudo de Exame Químico-Toxicológico, às fls. 173/175. É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial procede. Porém, com algum temperamento.

A materialidade do delito encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12, Laudo de Constatação de fls. 08/10 e Laudo Pericial de fls. 173/175, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, maconha.

A autoria do delito, ainda, ecoa da prova produzida, entretanto, não na extensão pretendida pela acusação.

Tudo porque, a meu sentir, não restou evidenciada, com confortável certeza moral, a responsabilidade do acionado pela prática do crime de tráfico.

De início, para que não se alegue omissão, não acolho o argumentado pela defesa, no sentido de que o flagrante estaria eivado de nulidade absoluta, em decorrência da alegada violação ao domicílio do agente.

Isso porque, consabido, nenhum direito é absoluto, nem mesmo os direitos fundamentais, constitucionalmente previstos, eis que limitados, inclusive, por outros direitos de igual envergadura axiológica.

Ora, no caso em tela, bem afirmaram as testemunhas policiais terem recebido informação de que o acionado estaria traficando substâncias entorpecentes, razão pela qual se dirigiram ao local dos fatos, ocasião em que o abordaram diante das fundadas suspeitas, o qual informou aos policiais da existência de drogas em sua residência, franqueando o acesso.

Neste contexto, verifica-se que havia motivos idôneos para que os policiais suspeitassem da residência em questão, realizando, assim, a competente averiguação, motivos estes que, ao final, se confirmaram, visto que apreendida boa quantidade de droga acima descritas.

Assim, e em se tratando o delito em questão de natureza permanente, tem-se que o flagrante se protraí no tempo, podendo a incursão em residência, ainda que habitada, ser realizada em qualquer horário do dia ou da noite, nos exatos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência em uníssono:

Afinal, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de tráfico de drogas nas modalidades guardar e ter em depósito é de natureza permanente (cf. art. 303 do Código de Proc. Penal), assim entendido aquele cuja consumação se protraí no tempo, não se exigindo a prévia obtenção de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do suspeito quando tal se faz necessário para fazer cessar a atividade criminosa, algo que a ordem jurídica considera factível não apenas por membros das corporações de segurança, mas também por “qualquer do povo” (cf. art. 301 do CPP), dada a situação de flagrância.

Nesse sentido, confirmam-se as seguintes ementas [sem destaques nos originais]:

“A jurisprudência desta Corte é segura no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente. Precedentes. [...] No que tange à suposta ilegalidade da prisão em flagrante e das provas colhidas durante a diligência policial, o entendimento perfilhado pela Corte 'a quo' está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ainda, a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial. Precedentes. [...] Writ não conhecido. (HC 404.980/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é

o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1574795/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016)"

"[...] Este Tribunal tem reputado dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. (RHC 54.972/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015)."

E ainda, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus com pedido de liminar - Tráfico ilícito - Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Alegação de ilegalidade da constrição - Ingresso em domicílio sem mandado de busca e apreensão - Inexistência de eiva - Paciente preso em flagrante em decorrência do cometimento, em tese, de crime de natureza permanente (CF art. 5º, XI, segunda parte, e CPP, art. 303) - Decisão motivada e que atende às exigências legais (CF, arts. 5º, LXI, e 93, IX; CPP, arts. 283, 310 e 315) - Presença dos requisitos previstos no art. 312, caput, do mesmo codex. (...) Ordem denegada."

Destarte, pelo exposto, tenho como absolutamente lícita a ação dos policiais, não havendo se falar em violação de domicílio, eis que a propriedade imóvel não recebeu proteção constitucional para que fosse utilizada na prática de delitos, o que seria verdadeiramente teratológico.

Ademais, prova maior da autorização se dá pelo fato de que o acionado mesmo abriu a porta da casa (portão da casa) e revelou aos policiais a senha de desbloqueio de seu aparelho de telefone celular, cujo parcial conteúdo indica manipulação de drogas, consoante verte do relatório acostado aos autos.

Pois bem!

Interrogado na fase policial, o acionado optou pela negativa (fls. 06), afirmando ser usuário de substâncias entorpecente.

Em Juízo, não se portou de forma diversa, afirmando que a droga apreendida era destinada a seu consumo pessoal.

E, verdade seja dita, o restante da prova não veio de molde a indicar o contrário. As testemunhas de Defesa deram indicação da boa conduta do acionado, trabalhador, residente com a família, pessoas que não viam movimentação estranha no local, o que seria de se esperar, caso ali fosse um local de mercancia.

Os policiais civis, por sua vez, bem narraram que na data dos fatos receberam a informação de que o acionado estaria traficando substâncias entorpecentes, razão pela qual foram ao local dos fatos, fizeram campana e não notaram movimentação estranha no local. Mesmo assim, avistaram o acionado saindo da sua casa, razão pela qual, em fundadas suspeitas o abordaram, mas preliminarmente nada de ilícito fora encontrado em seu poder. Porém o mesmo tomou ciência dos fatos e disse que havia droga dentro da sua casa, franqueando o acesso, os quais localizaram um tijolo de maconha escondida atrás das prateleiras da cozinha, o skunk a granel sobre a mesa e os invólucros escondidos dentro da gaveta, debaixo dos panos de pratos, motivo pelo qual foi dada voz de prisão ao acionado, sendo o mesmo apresentado na unidade de polícia judiciária. Outrossim, informaram que no aparelho celular do acionado, no campo das fotos havia diversas fotos e vídeos com apresentação de tijolos de maconha e Skunk, haja vista que o mesmo autorizou acessá-lo.

Tais provas revelam, então, o encontro do entorpecente, em seu estado bruto, na residência do acionado, certo que o volume, malgrado aparentemente elevado, por si só, não dá efetiva indicação da destinação mercantil, mesmo porque, sequer balança de precisão foi apreendida no local, o que seria de se esperar, caso fosse o afirmado mercador.

Por certo, o relatório de fls. 295/320, causa algum impacto negativo.

Contudo, me causa estranheza seu teor, sem que pese contra seus subscritores alguma dúvida quanto a retidão de conduta, na medida em que não esclarecido o meio pelo qual houve acesso tão fácil ao dispositivo, quando, o próprio instituto de criminalística não conseguiu (fls. 329/333).

Logo, não se mostra possível cotejar tal dado probatório, com a segurança

reclamada, de forma a indicar dedicação à traficância.

Em verdade, houvesse durante a instrução confirmação de que já fora o acusado visto ou mencionado como pessoa conhecida no meio como traficante de drogas, até se poderia cogitar de solução diversa.

Mas o fato é que nada, absolutamente nada há nos autos a indicar fosse ele um efetivo mercador, a quantidade da droga, no caso, até certo ponto acima do normal evidenciado em outros casos envolvendo usuários, verdade seja dita, não se mostra tamanhamente expressiva, e me parece compatível com sua condição pessoal, consoante nos dá conta o documento de fls. 83/85, razão por que, em relação a ele, acusado, a solução que melhor se delineia é mesmo a de desclassificação do delito, já que para se determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal ou não, dentre outros fatores, deve o juiz atentar não só à quantidade da substância apreendida, mas, também, eventual diversidade de substâncias (inexistente no caso), ao local e às condições em que se desenvolveu a ação (art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06). Nesta quadra, a desclassificação se impõe para o disposto no art. 28, da Lei Federal nº 11.343/06.

Verificada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Neste quadro, atento à finalidade retributiva/preventiva da sanção penal, e mesmo conferindo oportunidade ao acionado de sentir-se útil à sociedade, com vistas a incutir no seu íntimo a necessidade de mudança de postura, ainda, ocupando seu tempo em atividade salutar, de forma a vê-lo afastado do ambiente pernicioso dos desocupados e usuários, opto pela pena de prestação de serviços à comunidade, a qual é fixada pelo prazo de quatro meses (artigo 28, inciso II).

Os serviços serão prestados em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos assemelhados, públicos ou privados, sem fins lucrativos e que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários de drogas.

De qualquer modo, as entidades serão especificadas pelo juízo das Execuções Criminais.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em discussão.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu FELLIPE CORDEIRO MORATO ao cumprimento de pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade em favor de entidades e programas comunitários que serão especificados pelo Juízo da Execução, por quatro meses, por haver infringido o disposto no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06.

Defiro o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o acionado com as custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06